

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

35ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno dia 04/12/2024

Exame Prévio Municipal

Processo Eletrônico e-TCESP Nº 21278.989.24

Representante: Adriano de Souza Lustosa.

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ.

Objeto: Representação contra possíveis irregularidades no Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo nº 109/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá objetivando a contratação de empresa para locação de 12 (doze) ônibus com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) lugares cada

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL.

Contratação de empresa para locação de 12 (doze) ônibus. Exigência de atestados de capacidade técnica “acompanhado das devidas notas fiscais comprobatórias”. Cláusulas editalícias contraditórias e omissas acerca da garantia de proposta e prazo de vigência do contrato. Carência de prazo razoável para disponibilização dos veículos, profissionais e demais documentos necessários à execução do objeto. Prazo para defesa prévia abaixo do mínimo legal. Vindicação de prova de regularidade fiscal relativa a tributos alheios à atividade lícita.

Relato, em sede de exame prévio de edital
Representação formuladas por Adriano de Souza Lustosa contra o edital de Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo nº 109/2024, certame promovido pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá objetivando a contratação de

empresa para locação de 12 (doze) ônibus com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) lugares cada.

A petição foi protocolada no dia 14/10/2024 enquanto que a data de abertura das propostas estava marcada para o dia 16/10/2024.

O Representante questiona, em síntese, os seguintes pontos do edital:

- (i) inexistência de amparo legal para exigência de atestados de capacidade técnica “acompanhado das devidas notas fiscais comprobatórias” - item “7.3.1.” do edital;
- (ii) vindicação restritiva de veículos em “nome da empresa proponente e/ou proprietário legal da mesma”, sem possibilitar a utilização de outras formas de comprovação de posse dos bens, a exemplo dos contratos de locação, doação e/ou comodato - item “7.3.4” do edital;
- (iii) possível ampliação indevida do rol de impedimentos de licitar - item “2.1.6 do edital;
- (iv) cláusulas editalícias contraditórias e omissas acerca da garantia de proposta e prazo de vigência do contrato, podendo culminar em afronta às Súmulas 24, 37 e 38 do E. TCE/SP e com impactos, inclusive, nas condições de participação e habilitação do pregão - itens “2.1.1”, “7.1.3.1.”, “7.3.2.”, “16.9.”, 17.1.” e “18.5” do edital;
- (v) carência de prazo razoável para disponibilização dos veículos, profissionais e demais documentos necessários à execução do objeto e, por consequência, para início da prestação dos serviços – itens “7.3.4”, “16.1” do edital e item “3.4.” do Termo de Referência;
- (vi) prazo para defesa prévia abaixo do mínimo legal - item “2.1.6 do edital; e
- (vii) vindicação de prova de regularidade fiscal relativa a tributos alheios à atividade licitada – item “7.1.2.”, alínea “d” do edital.

O certame encontra-se suspenso conforme despacho publicado no DOE de 16/10/2024 com referendo do Tribunal Pleno na sessão de 23/10/2024.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ apresentou suas justificativas.

Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG manifestaram-se pela procedência parcial da Representação.

É o relatório.

VOTO.

Procede a queixa contra a exigência de atestados de capacidade técnica acompanhados de notas fiscais porque desborda do rol do art. 67 da Lei n.º 14.133/2021.

Da mesma forma procede a crítica contra a exigência de que os veículos estejam em nome da empresa proponente e/ou proprietário legal dela, vez que a nossa jurisprudência indica para que a Administração possibilite expressamente que a comprovação de posse dos veículos se dê por qualquer meio admitido em direito, tais como leasing, arrendamento mercantil, locação ou comodato.

Também deve ser aprimorado e retificado o edital para adequação à Súmula nº 37 deste TCESP, que prevê *“em procedimento licitatório para contratação de serviços de caráter continuado, os percentuais referentes à garantia para participar e ao capital social ou patrimônio líquido devem*

ser calculados sobre o valor estimado correspondente ao período de 12 (doze) meses”.

Prosseguindo, deve ser ajustada a divergência quanto ao prazo de vigência do ajuste (60 meses, prorrogáveis até 120 meses - itens 16.9 e 18.5 do edital; ou 1 ano, prorrogáveis por mais 4 anos – itens 5.1 do Termo de Referência e Cláusula Segunda da Minuta de Contrato).

Procede ainda a impugnação sobre a exiguidade do prazo para disponibilização dos veículos, profissionais e demais documentos e início dos serviços. Como bem destacado pela ATJ *“a concessão de diminuto prazo para disponibilização dos veículos, profissionais e demais serviços necessários à execução dos serviços, ainda que indiretamente, impõe que as interessadas providenciem os meios necessários à prestação dos serviços previamente a disputa e/ou privilegia empresas que já prestam os serviços à municipalidade, hipótese que, por restringir a competitividade e/ou direcionar o certame a atual prestadora dos serviços, tem sido reiteradamente rechaçada por este E. Tribunal”.*

Também procedente a queixa contra o prazo para apresentação de defesa prévia em processo administrativo (5 dias úteis), pois “deverão ser aplicadas as disposições do artigo 157 da Lei 14.133/21, a qual estabelece que, na aplicação da sanção prevista no inciso II do artigo 156, o interessado tem direito a se defender no prazo de 15 dias úteis, a partir da data de sua intimação”.

Acompanho a posição da SDG quanto a existência de cláusulas editalícias contraditórias e omissas acerca da garantia de proposta, indicando que existe provável erro de digitação no item 2.1. eis que, como mencionado embora o item preveja que “Não será permitida a participação nesta licitação, de empresas que NÃO tenham apresentado a GARANTIA DE PROPOSTA,

nos termos do item 7.1.3.3.1. deste Edital”, o item mencionado (7.1.3.3.1) sequer consta do ato convocatório, e tampouco existe outra cláusula que discipline a referida “garantia”.

É procedente o questionamento acerca da exigência de prova de regularidade de ICMS porque conforme precedente jurisprudencial citado (TC-017428.989.22-2), *“a exigência de comprovação da regularidade fiscal com a Fazenda Estadual relativa ao ICMS é prática reprovada por esta r. Corte de Contas para serviços de transporte escolar de natureza exclusivamente ‘municipal’”*.

Por fim, em relação ao rol de impedimentos de licitar, não existe qualquer irregularidade a sanar, porém considerando que o certame sofrerá correções, recomendo que se aprimore a redação da cláusula editalícia, passando a constar “Administração do Município de Mongaguá/SP”.

Improcedente a insurgência sobre o item 16.9, tendo em vista que o §5º do art. 67 da Lei 14.133/21 estipula que nas contratações de serviços contínuos, existe a possibilidade da exigência de comprovação de serviços similares ao objeto da licitação, por um prazo mínimo de até 3 (três) anos, computados em períodos sucessivos ou não.

Pelo exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO, determinando que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ retifique o edital, republicando-o para atender ao disposto na legislação vigente.

É o meu VOTO.

Após as providências de praxe encaminhe-se o processo ao Arquivo.



GABINETE DO CONSELHEIRO
ANTONIO ROQUE CITADINI
(11) 3292-3347 - gcarc@tce.sp.gov.br



ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

GNA